

1503344-27.2021.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/10/2022

... de Justiça do Estado de São Paulo:

"Tráfico de entorpecente. Réus flagrados promovendo o tráfico no local. Quantidade de 16 porções de cocaína, pesando 22,52 gramas, e 4 porções de crack, com peso de 1,58 gramas. Campana policial. Depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares. Intenção negocial comprovada. Condenação mantida. Penas dosadas nos mínimos legais. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Sentença - Processo nº 1503344-27.2021.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503344-27.2021.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2033712/2021 - 02º D.P. BOM

RETIRO, 16060898 - 02º D.P. BOM RETIRO, 457/21/102 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2033712 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDINALDO JOSE DA SILVA

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

EDINALDO JOSÉ DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, segundo a denúncia (fls. 1/3), no dia 4 de fevereiro de 2021, por volta das 16h30, na Rua Sebastião Pereira, 245, Santa Cecília, nesta capital, trazia consigo e guardava, para entrega ao consumo de terceiros, 7 (sete) invólucros contendo 3,9g (três gramas e nove decigramas) de cocaína e 7 (sete) invólucros contendo 12,8g (doze gramas e oito decigramas) de maconha, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de R\$ 26,00 (vinte e seis reais), provenientes do comércio ilícito de

entorpecentes.

Narra a denúncia que, segundo apurado, policiais civis que realizavam diligências investigativas com o intuito de coibir a mercancia ilícita de entorpecentes avistaram o denunciado em atitude suspeita, olhando de um lado para o outro de maneira desconfiada, como se estivesse à espera de alguém, de modo que, ao perceber a aproximação da viatura, passou a demonstrar nervosismo, momento em que os policiais deliberaram por abordá-lo.

Segundo a inicial, na revista pessoal, foram encontrados, no bolso direito dos shorts do denunciado, 4 (quatro) porções contendo substância semelhante à cocaína e, no bolso esquerdo, foi encontrado o valor de R\$ 26,00 (vinte e seis reais) em espécie. Ainda, no chão, sob um cobertor, ao lado do pé de EDINALDO, foram encontradas mais 3 (três porções) de substância aparentando ser cocaína e 7 (sete) porções com substância semelhante à maconha.

Em solo policial, o denunciado optou pelo direito constitucional de permanecer calado (fl. 9).

O laudo de constatação de fls. 27/30 restou positivo para 3,9g de cocaína e 12,8g de maconha.

Assim, a exordial conclui que as circunstâncias, variedade e forma de acondicionamento evidenciam que o denunciado trazia aquelas drogas para a entrega ao consumo de terceiros.

Por decisão proferida em 5 de fevereiro de 2021, a prisão em flagrante do denunciado foi homologada e convertida em prisão preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal (fls. 53/57).

Aos 8 de fevereiro de 2021, a ilustre Defensoria Pública impetrou habeas corpus a favor do autuado (fls. 69/77).

Por r. decisão proferida em 9 de fevereiro de 2021, o pedido de liminar nos autos do Habeas Corpus nº 2020342-66.2021.8.26.0000 foi indeferido (fls. 78/80).

Por decisão datada de 16 de fevereiro de 2021, foi determinada a notificação e citação do acusado (fls. 109/110).

Aos 18 de fevereiro de 2021, o i. Defensor Público requereu a revogação da prisão preventiva do denunciado (fls. 118/122).

O Laudo Pericial nº 52.885/2021 foi juntado às fls. 129/131.

Por decisão datada de 19 de fevereiro de 2021, foi concedida liberdade provisória ao réu, devendo ele comparecer a todos os atos processuais e informar número de telefone celular (e endereço de e-mail, se o possuísse), bem como se comprometer a não mudar de endereço sem prévia comunicação ao Juízo (fls. 134/135).

O réu foi citado (fls. 153/155) e a Defensoria Pública apresentou defesa prévia, requerendo, em suma, a rejeição da denúncia e/ou a absolvição sumária do acusado (fl. 159).

O recebimento da denúncia foi ratificado por despacho datado de 4 de março de 2021 (fl. 160).

O Laudo Pericial nº 47.510/2021, de Exame Químico-Toxicológico, foi juntado às fls. 185/187.

Aos 31 de outubro de 2022, para regularização formal dos autos, a denúncia foi recebida.

Durante a instrução processual em juízo, foram ouvidas as testemunhas policiais civis.

O réu não foi interrogado, tendo sido decretada sua revelia.

Encerrada a instrução, seguiram-se os debates orais.

O Ministério Público requereu, em síntese, seja a ação penal julgada procedente, com a condenação do Réu, nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública, por sua vez, requereu, em suma, a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu: a) a desclassificação da imputação inicial para o delito de porte de entorpecentes (art. 28 da Lei nº 11.343/06), pois, conforme já alegado, não há provas de que havia, por parte do acusado, intuito de comercialização da droga apreendida. Ora, no presente caso, o réu foi identificado como morador de rua, teria sido detido sozinho em via pública e a quantidade de entorpecentes supostamente apreendida em sua posse não é incompatível com a posse para consumo

próprio. De todo modo, para caracterização do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, em qualquer de suas formas, não basta a simples apreensão do entorpecente. Há que se comprovar a efetiva finalidade de mercancia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu no presente caso. É inadmissível a condução do agente apreendido com substância tóxica mediante meras presunções. Havendo dúvida com relação à destinação, a classificação deve ser feita pela espécie mais benéfica ao réu; b) a fixação de eventual pena no mínimo legal, pois o réu é primário, não ostenta antecedentes criminais e as demais circunstâncias judiciais lhe são amplamente favoráveis; c) a aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em seu grau máximo, diante da primariedade do réu e da ausência de comprovação de que se dedique ao tráfico ou de que faça parte de organizações criminosas para o mesmo fim, estando presentes, portanto, todos os requisitos legais; d) a outorga de regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, diante da culpabilidade em tese atenuada do acusado e considerando que a mera gravidade em abstrato do delito não implica, necessariamente, em tratamento penal mais rigoroso, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores; e) a concessão ao acusado do direito de apelar em liberdade, pois ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal colhe foros de procedência.

A conduta imputada ao réu subsume-se ao tipo incriminador do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram claramente a materialidade do delito narrado na denúncia, bem como que o réu é seu autor, constatando-se a inegável autoria.

Houve realmente a prática de crime de tráfico de entorpecentes, cuja materialidade restou confirmada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 5/6), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 10/13), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 16/17), pelo Laudo de Constatação (fls. 27/30), pelo Relatório Final de inquérito policial (fls. 86/87) e pelo Laudo de Exame Químico-Toxicológico (fls. 185/187), bem como pela prova oral colhida em juízo.

Com efeito, o Laudo de Exame Químico-Toxicológico revelou resultado positivo para as substâncias tetrahydrocannabinol, popularmente conhecida como maconha, e cocaína (fls. 185/187).

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

Foi ouvida em juízo a testemunha policial civil Cláudio Dian Júnior, que narrou, em síntese, que era operação na região da cracolândia e de maneira velada estacionaram em local próximo, talvez, trinta, cinquenta metros e ficaram observando grupo de pessoas. Tinha um morador de rua na calçada, conversando com outro rapaz. Se aproximaram e abordaram. Na revista encontraram no bolso quatro porções de cocaína e próximo dele encontraram um maço de cigarros com outras porções lá dentro. Indagado, ele disse que era usuário de drogas. Não se recorda se tinha dinheiro com ele. Quando se aproximaram o réu estava sozinho, a outra pessoa já tinha ido embora.

Foi também ouvida em juízo a testemunha policial civil Denis Vanzelli, que relatou que se lembra do caso, envolvendo morador de rua, encontraram pequenas quantidades de droga no bolso e no maço de cigarro dele e, antes disso, ficaram observando e viram que uma pessoa pareceu entregar algo para ele. Fizeram a abordagem e ele admitiu que tinha feito o comércio para se sustentar na região. Não lembra exatamente se o réu tinha dinheiro. Confirma seu depoimento na fase policial. O réu disse que estaria comercializando uma quantidade para se sustentar e consumir, também, por ser usuário. Uma pessoa se aproximou do réu, teve aquela troca, a distância era de cerca de trinta metros mais ou menos.

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais civis merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defensoria

Pública não apresentou qualquer razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador." (RT 616/286-7).

Dessa forma, considerando que nada há nos autos para infirmar as palavras dos policiais civis quanto à apreensão dos entorpecentes, não é lícito presumir que queiram prejudicar o acusado, pois agem em prol da coletividade, sendo, pois, seus depoimentos dignos de credibilidade.

A finalidade de narcotraficância foi perfeitamente evidenciada por alguns indícios irrefutáveis: a) pela natureza e diversidade das drogas apreendidas (maconha e cocaína); b) pela considerável quantidade de drogas (16,7 gramas no total, sendo 7 "papelotes" contendo cocaína e 7 invólucros contendo maconha), incompatível com a condição de mero usuário; c) pela apreensão de dinheiro e pela atividade observada pelos policiais e d) pelas circunstâncias da prisão. Todos esses fatores são indicativos do destino para consumo de terceiros.

Pelo que se vê, todos os elementos de prova complementam-se, formam um conjunto coeso e robusto no sentido de que o réu trazia consigo e guardava as drogas que foram apreendidas para o fim de comercializá-las, sendo certa a ocorrência do tráfico de entorpecentes, assim como sua autoria. Dessa forma, inadmissível seria a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

Assim, todas as provas colhidas não dão margem para outra conclusão senão a demonstração da materialidade do delito narrado na denúncia, bem como sua autoria. Passo à aplicação da pena, com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em primeira fase, verifico que, apesar de o réu ostentar condenação muito antiga por crime de receptação, deve ser considerado primário neste feito, uma vez já decorrido o período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, conforme se infere da Folha de Antecedentes (fls. 188/196) e da Certidão Estadual de Execuções Criminais (fls. 201/203). No mais, a culpabilidade do réu não ultrapassa o normal desvalor do tráfico de drogas, cometido em circunstâncias que não se mostram exageradas. Assim, nos termos do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena-base no mínimo legal, partindo de 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem contempladas.

Em terceira fase de aplicação da pena, aplicável a causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do mesmo artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. No caso em tela, o réu é primário e nada indica que integre organização criminosa ou que se dedique a atividades criminosas, de modo que estão inteiramente presentes as circunstâncias previstas no parágrafo 4º do citado artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que, somadas às circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, autorizam a redução máxima da pena prevista no preceito secundário do caput do artigo 33. Sendo assim, aplicando a causa de diminuição já mencionada, reduzo a pena-base em 2/3 (dois terços), chegando ao resultado de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, que, ante a inexistência de outras circunstâncias a serem apreciadas, torno definitiva.

Do regime inicial de cumprimento da pena.

Tendo em vista a primariedade e a quantidade de pena aplicada, fixo o regime inicial aberto para início de cumprimento da pena. Com efeito, o Colendo Supremo Tribunal Federal afastou a hediondez do tráfico privilegiado (STF, HC nº 118.533). No caso concreto, mostra-se razoável e recomendável o regime mais brando. Isso porque o réu é primário e não tem ligação comprovada com organização criminosa ou lucro pessoal relevante.

Vem a lume trecho de elucidativo julgado do Superior Tribunal de Justiça, Habeas Corpus nº 155.391/ES (2009/0234881-9). Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis

Moura. Data do Julgamento: 2 de setembro de 2010. Ementa:

"(...) Fixada a pena-base no mínimo legal e apreendida pequena quantidade de droga (0,2 decigramas) de crack, legítima é a aplicação da causa especial de diminuição (art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006) pelo seu máximo, ou seja, dois terços.

Precedentes. 3. A Sexta Turma desta Corte adotou o entendimento de que, ante o quantum de pena aplicado ao delito cometido sob a égide da Lei nº 11.343/06, é possível a fixação do regime semiaberto ou o aberto para o início do cumprimento da reprimenda reclusiva, em conformidade com o previsto no art. 33 do Código Penal, bem como da substituição da pena de reclusão por restritivas de direitos, em face do artigo 44 do Código Penal. (...)". (grifos nossos)

E, conforme já decidiu o Excelso Pretório:

"Ementa. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dezesseis gramas de cocaína e trinta e nove gramas de maconha. Crime praticado na vigência das Leis nºs 11.343/06 e 11.464/07. Aplicação da causa de diminuição em grau máximo. Possibilidade. Estabelecimento de regime prisional diverso do fechado. Possibilidade. Reprimenda inferior a quatro anos, reconhecimento da primariedade e ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Comando legal que deve ser compatibilizado com os princípios da individualização da pena e proporcionalidade. Substituição da sanção corporal por restritivas de direitos. Viabilidade. Precedentes do STJ e STF." (HC 168.679/SP, 2010/0064405-4. Relator Ministro OG FERNANDES. SEXTA TURMA. Data do Julgamento: 05/08/2010. Data da Publicação/Fonte: DJe 23/08/2010). (grifos nossos) Também conforme elucidativo julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Tráfico de entorpecente. Réus flagrados promovendo o tráfico no local. Quantidade de 16 porções de cocaína, pesando 22,52 gramas, e 4 porções de crack, com peso de 1,58 gramas. Campana policial. Depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares. Intenção negocial comprovada. Condenação mantida. Penas dosadas nos mínimos legais. Redutor aplicado à razão de dois terços. Regime fechado afastado. Reforma para o regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade. Parcial provimento." (Apelação nº 0005221-82.2012.8.26.0441. Relator Guilherme de Souza Nucci. São Paulo, 23 de fevereiro de 2016.). (grifos nossos)

Da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Diante da quantidade de pena aplicada e da primariedade do réu, cabível a concessão dos benefícios previstos nos artigos 44 e seguintes do Código Penal. Assim, tratando-se de pena superior a um ano, a pena privativa de liberdade será substituída duas penas restritivas de direitos, uma consistente na prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de serviço por dia de condenação, em entidade a ser indicada por ocasião da execução, e outra consistente em pena de prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, que se somará à pena de multa originária, com fundamento no artigo 44, § 2º, e no artigo 46, ambos do Código Penal.

DISPOSITIVO.

Diante de todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o acusado EDINALDO JOSÉ DA SILVA, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, da forma anteriormente especificada, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados pelo valor unitário mínimo. A pena de multa será calculada por seu valor unitário mínimo, atendendo ao disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Considerando a fixação do regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da

Lei de Assistência Judiciária.

Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do sentenciado no "rol dos culpados" e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Nos termos do artigo 480 e seguintes das NSCGJ, certificado o trânsito em julgado da condenação, expeça-se a certidão da sentença e abra-se vista ao Ministério Público para ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 31 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA